

1501628-10.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... a desclassificação do delito de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, aplicando a atenuante do art. 65, I do CP; o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º da Lei de drogas; detração da pena imposta com os dias que permaneceu preso preventivamente, substituição da pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501628-10.2021.8.26.0617 - Controle nº 2021/001036

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

ERICK TRANCHE DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

ERICK TRANCHE DE OLIVEIRA e WILLIAN SOUZA LEMOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 18h12min, na Avenida João Rodolfo Castelli, altura do nº 656, Jardim São Judas Tadeu, nesta cidade e Comarca, em concurso de pessoas caracterizado pelo vínculo subjetivo e divisão material de atos, estariam transportando, para fins de tráfico, 718 porções de cocaína, com peso líquido igual a 709,13g, e 185 pedras de crack, subproduto da cocaína, com peso líquido igual a 177,77 g, conforme laudo de constatação às fls. 12/15 e laudo de exame químico toxicológico de fls.137/139, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e espaço, ERICK TRANCHE DE OLIVEIRA e WILLIAN SOUZA LEMOS teriam se associado, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Notificados (fls. 185 e 188), os acusados ofereceram defesa preliminar (fls. 196). A denúncia foi recebida (fls. 199/200) e os acusados foram citados (fls. 216 e

218).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a fase probatória, o Ministério Público, em memoriais, pugnou pela parcial procedência da ação penal com a condenação dos réus como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como a absolvição em relação ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 297/327).

A Defesa do réu Willian, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, no que tange ao delito previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. No tocante ao tráfico, postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal, compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, aplicação do benefício previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas, apesar da reincidência e recurso em liberdade. Também pediu diminuição da pena de multa (fls. 331/340).

Por fim, a Defesa do réu Erick requereu a absolvição do acusado. Alternativamente, requereu a desclassificação do delito de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, aplicando a atenuante do art. 65, I do CP; o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º da Lei de drogas; detração da pena imposta com os dias que permaneceu preso preventivamente, substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito e recurso em liberdade (fls. 341/357).

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 03/06, laudo de constatação provisória de fls. 12/15, auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, bem como laudos de exames químico-toxicológicos de fls. 137/139, com resultado positivo para cocaína.

A autoria do tráfico ficou seguramente caracterizada em relação aos réus.

Na fase pré-processual, Erick e Willian permaneceram em silêncio (fls. 18 e 19).

Em juízo, Erick disse que fazia "bico" de motorista de aplicativo e foi solicitado pelo corréu, seu conhecido, para fazer uma corrida de Caraguatatuba a São José dos Campos. Ele disse que viria a esta cidade resolver uns problemas, mas traria consigo uma droga na volta. Não sabia que Willian pegaria grande quantidade de droga, pensou que ele traria entorpecente para seu uso.

Willian, por sua vez, disse que estava passando por dificuldades financeiras e aceitou oferta de buscar droga em São José dos Campos para trazer até Caraguatatuba. Ganharia R\$ 1.000,00 pelo serviço, sendo que pagaria R\$ 350,00 para Erick, que tinha ciência do que seria transportado.

A versão do acusado Erick não merece credibilidade, tendo sido contrariada pelo próprio corréu Willian, que revelou que Erick sabia do transporte da droga e anuiu com o transporte nestas condições.

Por sua vez, os policiais militares Nelson e José, ouvidos na fase extrajudicial, bem como sob o pálio do contraditório, narraram que foram informados através de uma denúncia anônima via COPOM de que um veículo GM/Onix vermelho, PLACA FLO0C38, estaria a serviço do tráfico. Em patrulhamento pelo Bairro do Putim, mais precisamente pela Avenida João Rodolfo Castelli, conseguiram abordar o veículo Onix vermelho. Revistaram ambos pessoalmente, mas nada de ilícito foi encontrado. Na revista ao veículo, contudo, sob o banco do passageiro, havia a droga que foi apreendida, crack e cocaína. O motorista Erick disse ser motorista de aplicativo e estava à serviço do passageiro Willian, vindo de Caraguatatuba, parando aqui em São José dos Campos e retornando à Caraguatatuba, pela quantia de R \$350,00 (trezentos e cinquenta reais). Já o passageiro confessou ser "mula" (aquele que transporta quantidade de entorpecente) e ganharia pelo "serviço" a quantia de R\$ 1.000,00. No local, Erick confessou que sabia que o trabalho do passageiro Willian envolvia transporte de entorpecente. Diante dos fatos, deram voz de prisão e os apresentaram na Unidade Policial (fls. 16/17).

Com efeito, os relatos dos policiais permitem concluir com segurança que houve a apreensão de grande quantidade de cocaína e crack no interior do veículo conduzido por Erick, sob o banco do passageiro, onde Willian estava sentado, sendo que os

entorpecentes eram evidentemente destinados ao tráfico, tendo em vista a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento. Além disso, Willian confessou seu envolvimento com o tráfico, tendo Erick informado que sabia que Willian transportava as drogas. Inclusive ambos admitiram em juízo que sabiam das drogas, não sendo crível a versão de Erick de que pensou que o entorpecente era para consumo de Willian pelo valor combinado que ambos receberiam e porque viu o pacote com grande quantidade de entorpecente, tendo ido busca-lo com o corréu. Assim, tampouco se pode cogitar da desclassificação da infração para o artigo 28, da Lei de Tóxicos. Neste passo, o tráfico de drogas se confirmou em relação aos acusados, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Contudo, o delito autônomo de associação para o tráfico não restou satisfatoriamente demonstrado, vez que não foi comprovado o vínculo estável e permanente entre os réus. A prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar que os réus estavam organizados e acostumados a agir em associação, permanente e estável, com a finalidade espúria do tráfico. Isto é, inexiste nos autos prova segura de que os agentes se reuniam, em caráter de habitualidade e permanência, de forma reiterada, para o cometimento do tráfico. Deste modo, a conduta dos acusados subsume-se apenas ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Formada a culpa, passo à análise da pena. Conforme se depreende da certidão de fls. 176/178 e 179/181, os réus possuem, cada um, duas condenações transitadas em julgado (processos nº 0005640-04.2017.8.26.0126 e 0007873-08.2016.8.26.0126 - Willian; 0006844-59.2012.8.26.0126 e 0009797-30.2011.8.26.0126 - Erick). Diante disso, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando-os portadores de maus antecedentes por uma de suas condenações, bem como pela grande quantidade de droga apreendida (mais de 800 g), fixo suas pena-base 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, no mínimo legal. Afasto a questão da inconstitucionalidade da multa do tráfico. Da mesma forma que a Constituição facultou ao legislador ordinário agravar a pena de crimes hediondos ou permitiu a diminuição da reprimenda em razão de circunstâncias que indicassem o menor potencial lesivo da conduta criminosa do agente, também facultou o aumento da pena de multa para crimes potencialmente mais graves em razão da própria natureza do delito, indicativa do lucro fácil, de modo que não há que se falar em inconstitucionalidade desta norma. A fixação do quantum de multa atende perfeitamente aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, já que balizados entre um mínimo e máximo. Na segunda fase, em face da reincidência de ambos, elevo a pena-base em 1/6, fixando-a em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. Embora Willian tenha confessado o crime, a reincidência é circunstância preponderante e não pode ser compensada com a atenuante da confissão. Destaco que este entendimento, consoante dicção lapidar do art. 67, do Código Penal, é harmônico com a Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 453.000 - Tribunal Pleno - Repercussão Geral - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 04.04.2013 - DJE 03.10.2013). Inclusive, como diferente não haveria de ser, tal entendimento é refletido pela Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gonçalves e pela tranquila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 105.543/MS - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 26.05.14; RHC 118.107/MG - Rel. Min. Teori Zavaski - j. 29.05.14; RHC 120.677/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 01.04.14 e RHC 115.994/DF - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 02.04.13). Neste sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO PROVIDO” (STF ARE 873289/DF Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA j. 13.03.2015 DJe 17.03.2015);

"(...) O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, 'a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada' (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli)" (STF HC 105543/MS Primeira Turma Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO j. 29.04.2014) ;

"(...) A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes (...) A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente" (STF RHC 115994/MS Segunda Turma Rel. Min. CARMEN LÚCIA 02.04.2013);

"(...) Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes" (STF RHC 120677/SP Segunda Turma Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI j. 18.03.2014).

Deixo de aplicar a benesse contida no artigo 33, parágrafo 4.º, da Lei 11343/06, pois os réus são reincidentes, o que por si só já afasta tal possibilidade. Torno a reprimenda acima definitiva à míngua de outros elementos modificadores. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os acusados ERICK TRANCHE DE OLIVEIRA e WILLIAN SOUZA LEMOS ao cumprimento das penas de 07 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, no piso, pela infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, absolvendo-os da acusação de terem infringido o disposto no artigo 35, da lei 11343//06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Os acusados não fazem jus a penas substitutivas e tampouco ao sursis em razão do tempo de pena imposto, bem como pela gravidade do crime de tráfico, que fomenta vários outros crimes, geralmente graves. Ademais, os réus são reincidentes e portadores de maus antecedentes.

Pelos mesmos motivos e pelas das circunstâncias do crime, bem como o comportamento e a personalidade dos réus, que transportavam grande quantidade de droga, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena é medida de rigor.

Mesmo estando presos desde 4 de dezembro de 2021, tempo que será oportunamente detraído de suas penas, o regime inicial de cumprimento de pena permanece o fechado, pela gravidade e consequências do crime anteriormente mencionadas, não sendo possível imposição de regime menos severo e análise, por este juízo de conhecimento, dos requisitos subjetivos e objetivos para progressão ou outro benefício da fase executória.

Não poderão apelar em liberdade pelo regime prisional imposto e porque a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser garantidas, permanecendo presentes os requisitos que fundamentaram a decretação de suas custódias cautelares, notadamente após a condenação e em função dos antecedentes.

Declaro o perdimento do dinheiro e dos celulares apreendidos nos autos em favor do FUNAD, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 63, da Lei 11.343/06.

Em relação ao veículo apreendido, INTIME-SE o requerente para regularizar o pedido nos termos mencionados pelo Ministério Público às fls. 296.

Após o trânsito em julgado, proceda a Serventia as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA